

1500652-08.2021.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Roberto Sylla

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... ao Copom, que estava realizando o tráfico. Afirma também que não foi localizado dinheiro com o réu.

O PM Douglas Antonio Moreas Barga, sob o crivo do contraditório declarou que estavam em patrulhamento e já haviam recebido via Copom informações de denúncias indicando a pessoa de Pedro Luis, vulgo "Ferrugem", que estava realizando o tráfico de drogas em sua residência na Rua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500652-08.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500652-08.2021.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO LUIS FREITAS CALIXTO ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Roberto Sylla

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra PEDRO LUÍS FREITAS CALIXTO ALVES, qualificado à fl. 11, imputando-lhe a prática do crime descrito nos artigos 33, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 28 de julho de 2021, por volta das 15h40, na Rua Denúncio David, nº 137, Parque Imperial, nesta Comarca de Presidente Prudente, o denunciado trazia consigo, guardava e tinha em depósito droga, para fins de fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em 25 (vinte e cinco) porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido total de 5,24g (cinco gramas e vinte e quatro centigramas - lacres nº 0035431 e nº 0035432), conforme boletim de ocorrência de fls. 13/17, auto de exibição e apreensão de fls.

20/21, laudos de constatação provisório de fls. 28/30, fotografias de fls. 22/25 e exame químico-toxicológico definitivo a ser oportunamente juntado. Segundo se apurou, o denunciado adquiriu as porções de crack acima mencionadas de terceira pessoa até o momento não identificada e passou a trazê-las consigo, bem como guardá-las e tê-las em depósito em sua residência, com vistas a comercializá-las ilicitamente. Inicialmente cumpre salientar que os policiais militares tinham prévios informes através do Detecta (fls. 18/19) indicando o denunciado como traficante de drogas e que ele as repassava aos usuários através do muro da sua casa. Diante disso, os agentes públicos se dirigiram ao endereço indicado pelo denunciante e, em frente à residência, abordaram o denunciado PEDRO, que estava em posse de 02 (duas) pedras de crack, além de 01 (um) aparelho de telefone celular. Os policiais ingressaram na residência de PEDRO e, em seu quarto, no interior de uma pochete marrom, que estava dentro de uma cômoda, localizaram mais 23 (vinte e três) porções de crack embaladas de forma semelhante às que o imputado trazia consigo em frente à casa (fls. 22/25), além de um canivete com resquícios da mesma droga e embalagens vazias. Considerando as circunstâncias em que se deram os fatos, confirmando as denúncias recebidas sobre o tráfico de drogas tendo como vendedor o denunciado, somada à quantidade e a forma de acondicionamento da substância entorpecente apreendida em sua residência, adquirida de pessoa até o momento não identificada, afigura-se quadro seguro a apontar que as porções de crack apreendidas seriam destinadas ao comércio espúrio de substâncias entorpecentes.". Acompanha a denúncia o respectivo inquérito policial.

Após regular citação apresentado defesa preliminar (fls. 146/155), sobre a qual o Ministério Público se manifestou (fls. 159/160), o despacho de fls. 161/165, de 1º de setembro de 2021, recebeu a denúncia e determinou a produção de provas.

Em alegações finais, o nobre Dr. Promotor de Justiça (fls. 261), pediu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, o ilustre Dr. Defensor Público (fls. 261), requer a absolvição do réu, por insuficiência probatória por insuficiência probatória, por não se vislumbra qualquer imputação ao réu dos verbos do tipo penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo, dessa forma a desclassificação da conduta do delito de tráfico de drogas para o previsto no artigo 28, da Lei nº 11343/06, pois o réu alegou, tanto na fase inquisitiva como em Juízo ser usuários de drogas.

Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, impugna o pedido do Ministério Público para exasperação da pena base em razão da quantidade de droga apreendida, que seja aplicada a pena no mínimo legal, em regime aberto, e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, reconhecendo a figura do tráfico privilegiado.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais e não havendo preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

A materialidade dos fatos narrados na denúncia e imputados ao réu, encontra-se suficientemente demonstrada nos autos pelo auto de exibição e apreensão de fls. 20/21; pelas fotografias de fls. 22/25; pelo laudo de constatação preliminar de fls. 28/30; pelo laudo químico toxicológico de fls. 103/105, atestando - Item 1 (Acondicionado sob o lacre 0035431) Descrição: 23 (vinte e três) invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por nó, interligados entre si, da seguinte maneira, 4 (quatro) grupos contendo 5 (cinco) unidades cada um, e 1 (um) grupo contendo 3 (três) unidades, todos, encerrando porção de material sólido petrificado, de cor bege. Massa Bruta e/ou Quantidade: 12,25 grama(s) - doze gramas e vinte e cinco centigramas. Massa Líquida: 4,84 grama(s) - quatro gramas e oitenta e quatro

centigramas, e Item 2 (Acondicionado sob o lacre 0035432) Descrição: 2 (dois) invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por nó, interligados entre si, encerrando porção de material sólido petrificado, de cor bege. Massa Bruta e/ou Quantidade: 4,87 grama(s) - quatro gramas e oitenta e sete centigramas. Ambas com Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); Laudo pericial de objetos de fls. 181/183, que analisou - Item A (Acondicionado sob o lacre 0016624) Descrição: Um invólucro(s) plástico(s) encerrando 1 (um) canivete, usado, em regular estado de conservação, da marca/modelo HX/Combined, dotado de uma lâmina em metal inox, retrátil (basculante ao cabo no sentido longitudinal da lâmina), pontiaguda e de um gume afiado. Seu cabo confeccionado por placas metálicas, dotado de abridor de garrafas e saca-rolhas. O objeto pode ser utilizado para fracionar substâncias entorpecentes. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas e foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, Item B (Acondicionado sob o lacre 0016623) Descrição: Um invólucro(s) plástico(s) encerrando 17 (dezesete) embalagens plásticas transparentes, de formato retangular, medindo 240 e 40 milímetros de comprimento e de altura. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas e foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, Item C (Acondicionado sob o lacre 0016622) Descrição: Um invólucro(s) plástico(s) encerrando 1 (uma) pochete em tecido do tipo lona, de cor marrom, usada, cda marca KVN. O objeto pode ser utilizado para transportar substâncias entorpecentes. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas e foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA; pelo laudo pericial no aparelho celular de fls. 134/140; além da prova oral carreada para os autos.

Em Juízo, o PM Amauri Aparecido Rodrigues, sob o crivo do contraditório declarou que participou da diligência que prenderam o réu na posse de drogas. Estava em patrulhamento pelo parque Imperial, na Rua Denúncio David, e pelo local avistaram David, sentado na calçada em frente a sua casa, e abordado, foi feita revista pessoal e com ele foi encontrado em seu bolso do lado direito, um aparelho celular e uma porção de droga. Indagado sobre a droga, disse que era para seu uso e que não traficava. Foi solicitada a entrada em sua residência, tendo ele autorizado, dizendo que não havia mais drogas. Durante as buscas na residência, sobre uma cômoda foi localizada uma pochete e dentro dela continha mais vinte e três pedras de crack, embaladas como as que foram encontradas com o réu na abordagem, também foi encontrado um canivete com resquícios de crack, embalagens e o canivete. Novamente foi indagado ao Pedro sobre as drogas, disse que havia adquirido em data anterior, e que era para uso, negando o tráfico. Na residência havia um quarto, porém encontrava-se fechado e ele disse que não se lembrava onde estaria a chave, pedindo auxílio para um chaveiro, e com autorização do Pedro foi aberto e nada mais foi localizado. Diante da situação, foi dada voz de prisão e encaminhado à Delegacia para formalização do flagrante. Afirma que havia denúncias anteriores junto ao Copom, que estava realizando o tráfico. Afirma também que não foi localizado dinheiro com o réu.

O PM Douglas Antonio Moreas Barga, sob o crivo do contraditório declarou que estavam em patrulhamento e já haviam recebido via Copom informações de denúncias indicando a pessoa de Pedro Luis, vulgo "Ferrugem", que estava realizando o tráfico de drogas em sua residência na Rua Denúncia David, 137, Parque Imperial. Intensificamos o patrulhamento no bairro e passando pela rua visualizamos o réu sentado em uma cadeira na calçada em frente a sua residência. Optamos por aborda-lo e em revista pessoal localizamos no bolso de sua bermuda, duas pedras de crack embaladas em plástico transparente, bem como um celular. Indagado sobre a droga, disse que era para próprio uso e que não vendia, diante das denúncia. Indagado também se havia mais drogas em sua residência, disse que não e de boa-fé, autorizou o ingresso da equipe em sua residência. Durante as buscas, em seu quarto, sobre uma cômoda, localizamos uma pochete e dentro desta localizamos mais vinte e três pedras de crack, um canivete com resquícios de crack, e embalagens plásticas idênticas a

que estavam embaladas as que foram encontradas com ele. E diante das denúncias, encaminhamos até a Delegacia de Polícia que formalizou o flagrante.

O réu Pedro Luis Freitas Calixto Alves, em seu interrogatório declarou que nunca foi preso e nem cumpriu pena anteriormente. Sobre os fatos disse que no dia dos fatos realmente estava em frente a sua casa, porém, estava somente com o celular, não tinha nenhuma pedra de crack em sua posse, pois elas estavam em cima da mesa em seu quarto e quando o abordaram já disse que tinha 25 (vinte e cinco) pedras de crack que era para seu uso, pois naquela época ainda usava, e hoje não usa mais, se converteu e está indo para a Igreja. Confirma que adquiriu as vinte e cinco pedras da forma que foram encontradas, comprou na linha atrás do Hotel Portal D'Oeste. Afirma que o canivete era usado para desfazer a droga para colocar no cachimbo para usar.

A negativa dos réus não pode ser acolhida, posto que além de não ser confirmada pela prova dos autos, está desmentida por ela, que demonstra de forma segura que os fatos se passaram como narrados na denúncia e a autoria dele pelo réu, principalmente quanto a forma que foi localizada a droga, o canivete com resquícios de droga, bem como a grande quantidade típica e pronta para a venda a terceira, portanto, nenhuma prova há da sua alegação, caindo em total descrédito diante de tudo o que foi amealhado aos autos.

Também não prospera a alegação de que a droga era para consumo próprio, já que também foi desmentida pela prova dos autos, vez que a Polícia Militar já vinha recebendo notícias pretéritas sobre a prática do tráfico de drogas no local pelo réu, bem como vizinhos próximos, que cansado da atividade criminosa, acabam denunciando, onde foi informado local e até mesmo o nome do réu(apelido), não havendo que duvidar da palavra dos policiais quanto as denúncias, pois foram juntadas aos autos no momento da lavratura do flagrante, mesmo que seja de difícil identificação do denunciante, haja vista o medo de represálias e acabarem por ser descobertos, e é o que aconteceu nos autos, por denúncia que usuário vão até a casa do réu, de dia e de noite, solicitam a droga pelo muro que lhes é passada pelo réu. Tais informações são carregadas de veracidade, não havendo motivos para serem descartadas, até porque foram confirmadas pela equipe da Força Tática da Polícia Militar que fizeram a abordagem e prisão do réu diante dos fatos e do contexto em que a droga foi localizada, em que pese a negativa do réu, que restou isolada nos autos.

Nesse caso, o depoimento dos policiais é suficiente para alicerçar a culpa do acusado, que deve provar sua inocência com os meios que obtiver.

Transcrevo decisões a respeito do crime ora tratado, relativamente à impossibilidade de desclassificação para uso de entorpecente, bem como sobre a credibilidade da palavra dos policiais envolvidos com a descoberta e detenção dos envolvidos:

“PROVA - Depoimento de policial que efetuou a prisão em flagrante - Declarações harmônicas e seguras - Suporte suficiente à condenação - Inteligência dos artigos 6º, III, e 202 do CPP. PROVA - Depoimento de policial - Credibilidade dos testemunhos em geral enquanto não apresentada razão concreta de suspeição. ((RT 668/275 - TJSP - rel. Des. Jarbas Mazzoni))”.

Nesse ponto, nunca é demais lembrar que “como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial” - “Prova criminal - Testemunha - Hipótese de Tóxico. Depoimentos prestados por policiais. Validade. Presunção 'iuris tantum' de agirem escorreitamente no exercício da função. (TJSP, RJTJSP 125/563). No mesmo sentido: (RT 591/313 e 654/278).

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que

esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. ((STF HC 74.608-0 de São Paulo rel. Min. Celso de Mello DJU 11.04.97, pág. 12.189))”

Observe-se que o depoimento dos policiais foi uníssono, seguindo no mesmo sentido e meros desencontros sobre circunstâncias acessórias e paralelas ao núcleo central do comportamento criminoso não são suficientes para retirar a credibilidade que merece a prova testemunhal produzida nos autos, conforme pretende a defesa.

Aliás, não há nos autos qualquer elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar gratuitamente a acusada, motivo pelo qual não se pode desmerecer a fala dos policiais pelo só fato de pertencerem aos quadros da Polícia Militar.

Sobre a validade do depoimento de policiais, relembro que o eminente Ministro Moreira Alves, quando atuava no Supremo Tribunal Federal, deixou assentado que “o simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento” (STF RHC Rel. Min. Moreira Alves JSTF-Lex 125/332).

O Tribunal de Justiça de São Paulo também já decidiu o seguinte:

“Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivo expressos no CPP determinando que a Polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza absolvição” (TJSP AC Rel. Carlos Bueno RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

Demais disso, tem-se que “em sede de repressão aos tóxicos, contrapondo-se à palavra do agente à do policial-condutor, prevalece o depoimento do miliciano, salvo existência de prova diversa em contrário” (TACRIM-SP AC Rel. Lauro Malheiros JUTACRIM 30/328), valendo acrescentar que “pequenas divergências em depoimentos prestados pelas testemunhas, sem ofensa à essência do que contém, não são motivos para torná-los imprestáveis” (TJRJ EI Rel. Antônio Carlos Amorim RTJE 70/278).

Os demais elementos de prova dos autos demonstram a ocorrência do delito de tráfico de drogas diante da conduta do réu, não só pela apreensão das drogas nos dias dos fatos, mas pela ocorrência dos fatos como informado através da Polícia Militar; não só da droga mas também, mas aliada aos demais objetos e a droga, muitas pedras de crack fracionadas, prontas para a venda.

Além disso, havia mais embalagens usadas para acondicionar droga. Por tudo isso, demonstrada, á saciedade, a atividade espúria realizada pelo réu no imóvel onde foi surpreendido.

Tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas contidos nos autos, anotando-se que a palavra da testemunha se reveste de coerência, robustez e segurança e não demonstra qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceita como elemento hábil à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-la, o que não fez.

Pelos detalhes acima extraídos da prova dos autos, não se pode acolher a negativa do réu e nem o pedido de desclassificação para o delito posse para consumo pessoal, já que é evidente a condição de traficante do réu.

Quanto à destinação dos entorpecentes apreendidos nos autos, imperioso salientar que o elemento subjetivo do tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos não é perceptível logo de início, mas através das circunstâncias externas do caso concreto, as quais acabam por traduzir a intenção dos agentes.

Na hipótese dos autos, a droga apreendida, aliada ao modo como foram encontradas, denota sua destinação ao comércio ilegal. Importante ressaltar, inclusive, que tanto no veículo do autor como escondido em sua residência, ambas demonstram a principal destinação das drogas, em maior gravidade, uma folha de papel com anotações diversas que contem contas, dados pessoas, valores, altíssimos para quem é motorista de aplicativo, bem como a balança encontrada na residência.

É o quanto basta para embasar a condenação.

Nesse sentido: “CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Circunstâncias que induzem a caracterização do delito. A existência de denúncias anônimas, a

diversidade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, parte embalada e pronta para a venda clandestina, são circunstâncias que induze a caracterização do tráfico.” (Apelação Criminal n.º 223.036-3 - Sorocaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 01.07.97 - V.U.);

“TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Circunstâncias que evidenciam a condição de traficante - Recurso não provido. Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu, no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a sua prisão.” (Apelação Criminal n.º 152.279-3 - Marília - 3ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 19.06.95 - V.U.).

“ENTORPECENTE - Tráfico - Configuração - Materialidade e autoria demonstradas - Prova - Confissão policial de co-réu - Retratação judicial isolada - Palavra de policiais - Validade - Quantidade e modo de acondicionamento que revelam o fim de comércio - Flagrante preparado - Inocorrência - Pena - Pretendida substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Crime hediondo Regime integralmente fechado - Manutenção - Recursos não providos.” (Apelação Criminal n. 281.880-3 - Guaratinguetá - 4ª Câmara Criminal - Relator: Passos de Freitas - 08.02.00 - V.U.).

Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado.

Nesse sentido: “Não é indispensável a aprova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido” (TJSP RT 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3,3.8.94, p.8745);

“Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão” (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95 Rel. Des. Bittencourt Rodrigues).

No caso dos autos a polícia recebeu várias denúncias com informações que o réu vinha realizando o tráfico de drogas no local e da forma como constatarem os policiais.

Diante de tudo que foi amealhada aos autos, impossível acolher o pedido da Defesa do réu para desclassificação do delito de tráfico para o de porte de droga para consumo pessoal, já que, ao contrário do que alega a defesa, as provas produzidas são suficientes para crer que o réu realizava efetivamente o comércio de drogas em sua residência, procedendo a ação penal como pedido na denúncia.

Por fim, conclui-se, destarte, que o réu realizara conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se lhe a condenação e a pena, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Por tudo isto é que procede a ação penal e é de rigor a condenação do réu por tráfico de drogas.

Passo a dosagem da pena.

Passo a dosagem da pena.

No tocante ao pleito do Ministério Público quanto a exasperação da pena base em decorrência da quantidade, da diversidade das drogas e sua natureza, não há como acolher.

A circunstância específica prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, em razão da exasperação da pena base em razão da apreensão da quantidade, diversidade e natureza da droga, e a aplicação desses mesmos motivos, quantidade, diversidade e natureza das drogas para negar a redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem-se que não é possível por violar o princípio do bis idem bis.

“Habeas corpus. 2. Dosimetria. 3. Tráfico de drogas. 4. A quantidade de drogas, por si só, não pode proporcionar a presunção de que o paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição

de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 5. Quantidade da droga valorada na primeira e na terceira fase da dosimetria. Bis in idem. Desproporcionalidade no cálculo. 6. Ordem concedida para que seja refeita a dosimetria, nos termos do acórdão. (STF; HC 145362, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020 PUBLIC 20-03-2020).

Neste ponto, é forçoso reconhecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos HCs n.º 112776 e n.º 109193, em 19/12/2013, decidiu que não é possível a utilização cumulativa da quantidade e da natureza da droga na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer em bis in idem:

"[...] HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. BIS IN IDEM. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º, DO ART. 2º, DA LEI 8.072/1990. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONDEDIDA. 1. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". Configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). Essa opção permitirá ao juiz aplicar mais adequadamente o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) em cada caso concreto. 2. O magistrado sentenciante considerou a natureza e a quantidade de droga simultaneamente na primeira e na terceira fase de individualização da reprimenda, em flagrante bis in idem. [...]" (HC 112776, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

Também decidiu: "[...] HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA SOMENTE NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PACIENTE CONDENADO À PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, I, DO CP. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". Configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). Essa opção permitirá ao juiz aplicar mais adequadamente o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) em cada caso concreto. 2. No caso, a natureza da droga apreendida foi utilizada somente na terceira etapa da dosimetria, ou seja, para fixar o fator de redução da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6, não havendo, portanto, violação ao princípio do ne bis in idem. [...]" (HC 109193, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

Portanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de bis in idem caso a mesma circunstância (quantidade e natureza da droga) seja utilizada nas primeira e terceira fases da dosimetria, mas admitiu que tal circunstância possa ser avaliada em qualquer delas (desde que apenas em uma).

Presente a causa de diminuição em comento, entendo que a quantidade e a natureza da droga devem ser levadas em consideração apenas na terceira fase, para fins de estabelecimento do quantum de redução da pena, pois, caso contrário, conforme reconheceu o próprio STF, "o julgador ficaria limitado a aplicar, indistintamente, a maior fração a todos os condenados que tivessem jus à redução, a acarretar uma uniformidade de apenamento, em flagrante violação dos princípios da isonomia, da proporcionalidade, da legalidade, da motivação e da individualização da pena".

"PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. MODULAÇÃO PELA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO APRECIADA NEGATIVAMENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante o entendimento firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (ARE 666334/RG), a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas tanto na primeira fase, para elevação da pena-base, quanto na terceira etapa, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Todavia, devem ser consideradas apenas em uma das fases, sob pena de bis in idem. [...]" (Acórdão n.1122497, 20170110292870APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/09/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018. Pág.: 169/173) "[...] 3. O Supremo Tribunal Federal entendeu que caracteriza bis in idem a análise da natureza e da quantidade da droga na primeira fase da dosimetria, para aumentar a pena-base, e também na terceira, para graduar a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. [...]" (Acórdão n.1110966, 20160110770556APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/07/2018, Publicado no DJE: 30/07/2018. Pág.: 97/114).

Ressalte-se que esse entendimento prevalece mesmo que os citados elementos (quantidade e natureza da droga) sejam cindidos em diferentes circunstâncias ou fases.

"[...] 1 - As circunstâncias especiais - natureza e quantidade da droga - devem ser examinadas conjuntamente, não podendo ser consideradas, cumulativamente, na primeira e na terceira fases da individualização da pena, pena de caracterizar bis in idem. [...]" (Acórdão n.1112143, 20170110075896APR, Relator JAIR SOARES, Revisora: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2018, Publicado no DJE: 01/08/2018. Pág.: 165/181).

"[...] 4. De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, a valoração da natureza e quantidade da substância entorpecente na primeira etapa da dosimetria para subsidiar a fixação de pena-base acima do piso legal, bem como para graduar a diminuição da pena diante do privilégio estatuído no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 configura bis in idem. Não se admite a separação dos vetores - quantidade e natureza - para esse fim. [...]" (Acórdão n.1077373, 20160110898110APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: 298/324).

A jurisprudência entende que, à míngua de critérios fornecidos pelo legislador, devem ser observadas a quantidade e a natureza da droga como critério de fixação da fração de redução da pena:

"[...] 3 A redução da pena pela fração mínima prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, se justifica pela natureza e quantidade das drogas apreendidas. [...]" (Acórdão n.994019, 20130111131885APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisora: SANDRA DE SANTIS, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 15/02/2017. Pág.: 244/255).

"[...] 5. Sendo o réu primário, de bons antecedentes e não comprovada a dedicação a atividades ou organizações criminosas, aplica-se a causa de diminuição prevista no §4º, art. 33, da LAD, porém, pela metade, tendo em vista a quantidade e a natureza da droga. [...]" (Acórdão n.953819, 20150110790220APR, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/07/2016, Publicado no DJE: 13/07/2016. Pág.: 99/126).

Portanto, levando-se em consideração a quantidade de drogas apreendida, entendo que

a aplicação da causa especial de diminuição de pena em comento na fração de 1/2 (metade) mostra-se proporcional.

Nesse sentido:

[...] 1. Não sendo a quantidade de droga apreendida irrelevante (720,88g de massa líquida de maconha), razoável a incidência da fração de ½ (metade) de diminuição (§4º do artigo 33 da LAD). [...]". (Acórdão 1160518, 20180110068803 APR, Relator: SILVANO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: 152/174).

"[...] 5. Na hipótese de reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, a quantidade da droga apreendida (588g de maconha) justifica a redução da pena no patamar de 1/2 (metade). [...]". (Acórdão 1123911, 20170110259838APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/9/2018, publicado no DJE: 17/9/2018. Pág.: 186/198).

"[...] 3 A dosimetria é irretocável quando a pena é fixada no mínimo legal nas duas primeiras fases e foi reduzida por metade na fase final, considerando a diversidade de drogas apreendidas e a sua natureza. [...]". (Acórdão 1000569, 20130110716564 APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 2/3/2017, publicado no DJE: 9/3/2017. Pág.: 57/74).

Nesse cenário, deve ser mantida a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração de 1/2 (metade).

Portanto, na dosagem da pena, levo em consideração que o réu é primário e não registra antecedentes, e as circunstâncias judiciais do artigo 59, lhe são favoráveis, fixo a pena base no mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias multa cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem considerada.

Na terceira e última fase, presentes os requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo que é aplicável a causa de diminuição de pena nele estabelecida.

Com efeito, a par da primariedade técnica, não se evidenciou ser o acusado pessoa dedicada a atividades criminosas ou integrante de organização criminosa.

As quantidades de drogas em poder do réu são diminutas, sendo possível crer que ele não se trata de criminoso contumaz.

Reduz-se, pois, em razão da quantidade de droga apreendida, a pena na proporção de 1/2 (metade), de modo a resultar em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagar 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia, tornando-a definitiva neste ponto, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, deve-se ponderar que, no julgamento do HC n. 111.840/ES, realizado em sessão extraordinária do dia 27/06/2012, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando, assim, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e outros a eles equiparados (os dados são do HC n. 312.654-SP, STJ, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 12/02/2015).

No caso concreto, considerando não só a primariedade e a ausência de antecedentes, mas também, a circunstância de não ser considerada a quantidade de droga apreendida com o réu, entende-se viável a fixação do regime inicial aberto.

Por outro lado, levando em conta as circunstâncias judiciais favoráveis, conforme antes apontado, entende-se também cabível, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal.

Há orientação jurisprudencial nesse sentido:

"Tráfico de drogas. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Elementos de prova suficientes para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Pena-base fixada no mínimo legal. Causa de aumento, prevista no art. 40, III, da Lei de

Drogas, que não se afigurou. Afastamento. Réus que preenchem os requisitos para a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Circunstâncias do crime que tornam proporcional a diminuição na fração máxima de 2/3. Fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão, ex officio, da pena reclusiva em restritiva de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Detração determinada. Analogia ao artigo 42 do CP. Apelo parcialmente provido para esses fins. (TJSP, Apelação n. 0070062-66.2010.8.26.0050, rel. Otávio de Almeida Toledo, j. 13/12/2011).

E ainda:

"Entorpecente Absolvição ou Desclassificação - Impossibilidade - Provas seguras que demonstram a prática do delito de tráfico. Penas fixadas no mínimo e aplica do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 no percentual de 1/5 - Redução em 2/3 Possibilidade. Penas. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Cabimento. Regime prisional inicial fechado Fixação conforme preceitua o § 1º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07 Apelação do réu provida parcialmente." (TJSP, Apelação n. 0006628-72.2010.8.26.0319, rel. Pedro Menin, j. 10/04/2012).

Assim, deve a pena privativa de liberdade ser substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e por uma pena pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente na data do pagamento em favor do Hospital da Esperança (do Câncer) de Presidente Prudente.

Em caso de revogação das penas restritivas de direitos, o réu cumprirá a pena corporal fixada nesta sentença no regime aberto.

ISTO POSTO e o que mais dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu PEDRO LUIS FREITAS CALIXTO ALVES, RG: 44586658, CPF: 356.390.668-81, nascido em 19/01/1989, natural de Presidente Prudente - SP, filho de Gilberto Calixto Alves e Rita Antonia Freitas, a cumprir a pena de (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e por uma pena pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente na data do pagamento em favor do Hospital da Esperança de Presidente Prudente (Hospital do Câncer); e a pagar a multa de valor correspondente a 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, cada dia no valor mínimo legal, por violação do artigo 33, caput, c/c o artigo 33, § 4º, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Em liberdade durante todo o processo, agora, concedo ao réu o benefício de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso que apresentar contra essa sentença.

INCONTINENTE, comunique-se esta sentença aos autos do Habeas Corpus nº 1500652-08.2021.8.26.0000, que figura como paciente o réu Pedro Luis Freitas Calixto Alves, em trâmite perante a 13ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo como Relator Desembargador Marcelo Semer.

Quando da execução a multa deverá ser corrigida monetariamente a partir da data dos fatos da denúncia.

Determino a imediata destruição do aparelho celular e demais objetos apreendidos nos autos posto que utilizados para o tráfico conforme demonstrou a perícia neles realizada.

Condeno o réu a pagar as custas processuais. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita. Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Presidente Prudente, 03 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA